

생성형 AI의 활용에 따른 저작권 침해와 형사정책적 개선방안*

강 미 영**

目 次

I. 들어가며	IV. 저작권 침해에 따른 형사책임과
II. 생성형 AI의 활용에 따른 저작권	개선방안
침해	V. 나가며
III. 저작권에 대한 제한	

I. 들어가며

2022년 하반기, 생성형 AI인 챗GPT의 등장을 시작으로 전 세계는 AI 열풍에 빠졌다.¹⁾

┃ 투고일자 : 2025년 2월 1일, 심사일자 : 2025년 2월 22일, 게재확정일자 : 2025년 2월 26일.

* 이 글은 한국형사법학회 · 경상국립대학교 지식재산전문인력양성사업단 공동학술대회(2024.09.28. 한국형사법학회 신진학자 포럼) 발표문을 수정 · 보완한 것이다.

** 부산대학교 법학전문대학원 강사, 법학박사

1) 2022년 11월 30일 OpenAI가 공개한 챗GPT는 출시 5일 만에 사용자 1백만 명, 두 달 만에 사용자 1억 명을 돌파하였고, 2023년 3월에는 문자를 넘어서서 이미지도 인식하는 GPT-4가 공개되며 큰 화제를 일으켰다. ; 김혜정 · 송현수 · 박용주, “인공지능(AI) 윤리 규제 동향 및 표준화 현황”, 인공 지능윤리연구 제3권 제2호, 한국인공지능윤리학회, 2024, 13면 참조.

생성형 AI가 그리는 웹툰, 이미지 재생, 그들이 작곡·작사한 노래 및 창법 복제를 통한 커버물 등 각종 콘텐츠 등이 많은 인기를 누리며 대중의 큰 관심을 끌었다. 생성형 AI는 빠르게 우리 사회에 스며들며 기술이나 예술 영역 뿐만 아니라 일상적인 생활 속에서도 다양하게 활용되기 시작하였다. 그러나 이와 동시에 AI로 인하여 발생한 각종 부작용과 역기능도 드러나며 기존에는 생각지도 못한 유형의 법적 문제도 야기하고 있다.²⁾

생성형 AI는 사람이 기존에 만든 대량의 데이터를 학습하여 그 패턴과 구조를 파악하고, 새로운 텍스트나 이미지, 비디오, 오디오, 3D 모델 등 각종 콘텐츠를 만드는 인공지능 모델을 말한다.³⁾ 인터넷에서 자동으로 수집한 대량의 데이터를 학습하여, 이를 바탕으로 새로운 생성물을 만들어내는 구조를 가지고 있어 학습하는 데이터가 매우 중요하다.

문제는 이러한 데이터들을 학습하는 과정에서 필연적으로 저작권 보호를 받는 저작물을 이용하는 행위가 수반된다는 점이다. 이에 따라 국외에서는 이미 생성형 AI에 대한 소송이 잇따르고 있고,⁴⁾ 국내에서도 생성형 AI 시장이 빠르게 커지는 만큼 저작권 관련 갈등은 곧 수면 위로 드러날 것으로 보인다.

저작권과 관련한 기존의 논의들은 인공지능이 만들어낸 생성물을 어떻게 취급할 것인가에 대한 문제가 대부분이었다. 저작권법상 보호하는 저작물은 인간의 사상과 감정을 표현한 창작물을 말하는데, AI가 생성한 창작물을 저작권법의 대상이 되는 저작물로 볼 수 있는지, 그리고 저작물로 본다면 이에 대한 권리를 누구에게 귀속시킬 것인지에 대한 것이 주 내용으로 인공지능이 저작자가 될 수 있는지가 큰 쟁점이었다.

이 글에서는 이미 여러 연구를 통하여 논의된 AI 생성물에 대한 저작권 인정 여부 문제는 제쳐두고, 조금 더 현실적인 문제로서 생성형 AI의 활용에 따른 저작권 침해 여부에 관하여 다루어 보고자 한다.

생성형 AI의 경쟁력은 얼마나 많은 데이터를 학습했는지에 따라 좌우되는데, 이렇게 학습되는 데이터는 누군가의 저작물일 수밖에 없다. 저작물을 이용할 때에는 해당 저작

2) “AI로 만든 영화, 메타버스 속 건축물...저작권 인정 어디까지”, 중앙SUNDAY, 2024.05.18. ; “‘생성형 AI, 저작권 침해’ 日 신문協, 구글 등 비판 성명”, 조선일보, 2024. 07. 19. ; “박명수도 놀란 AI 박명수의 비비 ‘밤양갱’커버, 저작권은 어디에?”, 미디어오늘, 2024. 08. 17.

3) 김효정·이호용, “이미지 생성형 AI의 학습데이터 이용과 원저작권자의 이해관계조정 - 저작물의 공정이용과 외부효과를 중심으로 -”, 강원법학 제72권, 강원대학교 비교법학연구소, 2023, 32면.

4) “대표 AI 음악 생성 서비스 ‘수노’·‘유디오’, 저작권 침해 혐의 피소”, 전자신문, 2024. 06. 25. ; 명순영·최창원, “소송당하는 ‘생성형 AI’ : 잘나가는 챗GPT · · · 저작권에 발목?”, 매경ECONOMY 통권 제2217호, 46-48면 참조.

물의 저작권자들에게 이용 동의를 받는 것이 가장 이상적이지만, 방대한 데이터를 짧은 시간 동안 수집하는 생성형 AI의 경우, 모든 저작권자들에게 이용 동의를 구하기는 어렵다. 그에 따라 저작권 침해 논란이 발생할 수 밖에 없다.

그럼에도 불구하고 현행법에는 생성형 AI가 학습을 위해 다른 저작물을 수집하는 행위에 대해 저작권 침해 여부를 판단할 명확할 근거 조항이 없다. 저작권위원회에서도 안내서를 통하여 각각의 사안에 대한 방향성만 제시하고 있을 뿐, 구체적인 판단 정도나 기준에 대해 밝히고 있지 않다.⁵⁾ AI 업계에서는 지나친 저작권 규제는 AI 산업 및 발전을 막는다는 것을 이유로 이를 저작권 제한 사유 중 하나인 ‘저작물의 공정한 이용’에 해당한다고 주장하기도 하고, 애초에 AI 학습을 위한 정보 수집은 저작권 침해로 보지 않도록 면책 규정의 입법화를 요구하고 있다. 그에 따라 이들의 주장에 대한 타당성 여부를 살펴볼 필요가 있다고 판단하였다.

아래에서는 생성형 AI가 기존의 저작물을 학습하는 것이 저작권 침해에 해당하는지, 공정한 이용이나 면책 규정을 통하여 타당성이 인정될 수 있는지 여부를 짚어본 후, 형사처벌의 근거가 되는 저작권 침해죄에 따른 처벌 가능성을 검토해 보고자 한다. 나아가 생성형 AI를 활용하는 과정에서 발생하게 되는 저작권 침해에 대한 형사책임과 형사정책적 개선방안도 함께 모색해 볼 것이다.

II. 생성형 AI의 활용에 따른 저작권 침해

생성형 AI의 활용에 따른 저작권 침해 문제는 크게 두 과정으로 나누어 살펴볼 수 있다. 우선 생성형 AI를 학습시키기 위하여 다른 사람의 저작물을 이용하는 행위, 즉 학습 과정에서 발생하는 문제와 최종적으로 만들어진 생성물이 기존의 저작물과 흡사한 경우, 즉 이용하는 과정에서 발생할 수 있는 문제이다.

1. 생성형 AI의 개발 및 학습 단계

생성형 AI는 이미 만들어진 이미지나 데이터를 학습하여 새로운 결과를 창작해 내는

5) 저작권위원회, 생성형 AI 저작권 안내서, 2023, 19면.

것으로서 학습 과정에서 다른 사람의 창작물을 필연적으로 이용할 수밖에 없다.⁶⁾ 그에 따라 학습을 위해 수집된 데이터가 저작물에 해당한다면, 수집 단계를 거친 데이터를 입력하는 과정에서 데이터의 디지털 복제가 필수이므로 복제권 침해가 발생한다.⁷⁾ 그리고 그런 데이터를 다른 서버로 전송하거나 원저작물에 변경을 가한다면 전송권과 2차적 저작물작성권도 문제된다.⁸⁾ 또 이러한 저작재산권 외, 저작인격권으로서는 동일성 유지권이 침해될 여지가 있다.

2. 생성형 AI의 생성물 생성 및 활용 단계

학습 단계를 거친 후, 생성형 AI의 최종 목표는 이용자가 원하는 콘텐츠를 제공하는 것이다. 생성형 AI로 만들어진 생성물은 변용적 이용이 일반적이기는 하나, 콘텐츠 제공을 위해 만들어진 최종 생성물이 원저작물과 유사하게 만들어지는 경우 저작권 침해 문제가 다시 발생할 수 있다. 이 경우에도 동일하게 복제권과 2차적 저작물작성권이 침해될 가능성이 높다. 또한 저작인격권으로서는 원저작물 변경에 따른 동일성유지권, 생성물에 원저작자의 성명이 표시되지 않은 경우 성명표시권도 문제될 수 있다.

3. 분쟁 사례

생성형 AI에 대한 저작권 침해와 관련하여 대표적인 사건으로 Getty Images (US) Inc. v. Stability AI Inc.가 있다.⁹⁾ 스톡사진¹⁰⁾ 제공업체인 Getty Images는 Stability AI가 학습을 위해 허락 없이 자신들의 이미지를 무단으로 복제하였다고 하여 저작권 침해를 주장하고 해당 모델의 삭제를 청구하는 소송을 제기하였다. 해당 사안은 AI의 학습 단계에서 저작물을 이용한 행위가 저작권 침해로 판단될 것인지, 미국의 공정이용 조항이 적용될 것인지가 쟁점이다.

6) 이지연·김원호, “저작물 학습자로서 생성형 AI의 저작권 침해 책임”, IP & Data 法 제4권 제1호, 인하대학교 법학연구소, 2024, 77면.

7) 조연하, 인공지능 창작과 저작권, 박영사, 2023, 216면 참조 ; 공정이용의 예외에 대한 인정여부에 관해서는 「III. 저작권에 대한 제한」 부분에서 후술한다.

8) 조연하, 앞의 책, 217면 참조.

9) Getty Images (US) Inc. v. Stability AI Inc. 1:23-cv-00135-UNA (2023.02.03.)

10) 특정 주제나 목적에 맞게 라이브러리나 데이터베이스에 저장되어 있는 사진들로, 라이선스를 구입하여 사용가능하다.

또, 우리나라에서도 네이버가 출시한 생성형 AI 서비스인 하이퍼클로바X와 관련하여 언론단체들과의 분쟁이 발생하였다.¹¹⁾ 하이퍼클로바X는 네이버 플랫폼을 기반으로 한 AI 모델로, 지식인·블로그 등 방대한 누적 데이터를 앞세워 한국형 LLM을 시현하는 데 충분한 학습데이터를 갖고 있다고 밝힌 바 있다.¹²⁾ 이와 관련하여 한국신문협회는 “정당한 권원 없이 뉴스 콘텐츠를 AI 학습에 이용하는 것은 언론사가 뉴스 콘텐츠에 대해 가지는 저작권을 침해하는 것”이라는 입장을 밝혔다.¹³⁾ 이에 대해 네이버는 생성형 AI 개발을 위한 뉴스 콘텐츠 이용에 대해 저작권법상 ‘저작물의 공정한 이용(제35조의5)’에 해당되어 저작권 침해가 아니라고 주장하였으나, 한국신문협회는 “원저작자의 시장을 침해해 피해를 줄 가능성이 있다”고 지적하며 공정이용에 해당하지 않는다고 반박하였다.¹⁴⁾

4. 소결

생성형 AI의 목적은 데이터 학습을 통하여 그 인공지능을 더욱 고도화시키는 것에 있다. 이 경우 필요한 데이터를 학습하기 위해 다른 사람의 저작물을 이용할 수밖에 없다. 타인의 저작물을 이용할 경우, 저작권자의 허락을 받아야하는 것이 원칙이며, 그렇지 않을 경우 복제권, 전송권 등의 저작재산권뿐만 아니라 저작인격권도 침해한다고 보아야 한다.

그러나 앞에 언급된 분쟁 사례처럼 AI 업계에서는 AI의 데이터 학습을 위한 저작물 이용은 저작권의 제한 사유인 ‘공정한 이용’으로 저작권이 제한되므로, 저작권 침해가 아니라고 주장한다. 「저작권법」 제2관(제23조~제36조)에는 저작권이 제한되어 저작권 침해가 되지 않는 경우를 규정하고 있다. 저작물의 공정한 이용도 이러한 제한 사유 중 하나로, 생성형 AI의 학습을 위한 복제, 전송, 2차적 저작물작성행위 등은 이 공정한 이용에 해당하는지에 따라 그 적법성이 결정된다. 이에 아래에서는 저작물의 공정한 이용에 대해 살펴보고, 생성형 AI의 학습이 저작권 제한 사유에 해당하는지 여부를 검토해 보고자 한다.

11) ““터질 게 터졌다”...지상파 방송 3사, 네이버에 저작권 침해 제기”, 아시아경제, 2025. 01. 13.

12) “네이버 초거대 AI ‘하이퍼클로바X’, 어떻게 만들었나”, 지디넷코리아, 2023. 07. 19.

13) “신문협회 “언론사 허락없는 생성형AI의 뉴스이용은 저작권 침해””, 동아일보, 2023. 08. 22.

14) “생성형 AI의 뉴스 무단 학습 막아야”, 경향신문, 2023. 12. 18.

Ⅲ. 저작권에 대한 제한

저작권은 자신의 저작물에 대해 배타적이고 독점적인 성격을 가지므로 저작권이 있는 저작물을 이용하려면 원칙적으로 저작권자의 허락을 얻어야 한다. 그러나 모든 경우에 저작권자의 사전 허락을 받도록 요구하는 것은 저작물의 이용을 위한 거래 비용을 증가시켜 저작물 이용자의 이용 의욕 및 저작물을 이용한 새로운 창작을 막게 된다. 저작물은 문화적 재산으로서 가능한 많은 사람에 의해 널리 이용되는 것이 문화 발전을 위해서는 필요하다. 따라서 저작권자에 대해 정당하게 보상하면서 다른 한편으로는 저작물을 공중이 널리 이용할 수 있도록 저작권자의 권리에 일정한 제한을 가하고 있다.¹⁵⁾ 공익적 차원의 지식산업과 문화의 발전을 위한 예외를 설정해 두어 일정한 경우 지식재산권을 제한하여 저작물의 활용을 촉진하고 있는 것이다.¹⁶⁾ 아래에서는 제한 규정 중 AI의 저작권 침해 문제와 관련이 있는 공정한 이용에 대해서 살펴보고, AI 저작권법 개정으로 입법을 요구하고 있는 면책 규정에 대해서도 함께 검토해 보고자 한다.

1. 공정한 이용

공정한 이용 조항은 저작물이 디지털화되고, 유통 환경의 변화에 따라 기존의 저작권법에 제한적으로 열거된 저작재산권 제한 사유 이외에도 환경 변화에 적극 대응할 수 있도록 하기 위해 2011년에 신설된 조항이다.¹⁷⁾ 공정이용이란 “저작권법에 의하여 부여되는 저작자의 권리를 적용할 경우 해당 저작물의 이용자는 저작권 침해를 구성하게 되지만 합리적으로 저작권자의 권리에 제한을 둬으로써 이용자가 침해로부터 면책을 받을 수 있는 특권 또는 침해에 대한 항변”으로 정의되며,¹⁸⁾ 이러한 공정이용의 법리는 저작권자 이외의 자가 저작권자의 동의 없이 저작권을 합법적으로 이용할 수 있도록 하는 제도적 장치로 여겨지고 있다.

「저작권법」 제35조의 5에 따르면, 타 저작재산권 행사 제한 사유(제23조부터 제35조

15) 정상조 (편), 저작권법 주해, 박영사, 2007, 451면 참조.

16) 박서현·가지현, “생성형 AI 창작물의 저작권 성립 여부 및 침해 요건 검토 - 창작성 판단 기준과 차용미술과의 비교를 중심으로-”, 디자인 이노베이션 연구 제12호, 서경대학교 부설 디자인연구소, 2024, 38면 참조.

17) 윤태식, 저작권법 (제2판), 박영사, 2021, 277면 참조.

18) 최승재·김시열, 저작권법, 법문사, 2024, 302면.

의4까지, 제101조의3부터 제101조의5까지)에 해당하는 경우를 제외하고, ① 저작물의 일반적인 이용 방법과 충돌하지 아니하고 ② 저작자의 정당한 이익을 부당하게 해치지 아니하는 경우에는 저작물을 이용할 수 있다. 여기서 ① 저작물의 일반적인 이용이란 해당 저작물이 일반적으로 지향하고 있는 것으로, 저작물의 통상적인 시장과 경쟁 관계에 있는 이용행위는 원칙적으로 금지한다는 것이다.¹⁹⁾ 또, ② 저작자의 정당한 이익을 부당하게 해치지 않아야 한다는 것은 비록 그 저작물의 이용이 통상적인 이용이라고 하더라도 그러한 이용이 저작자의 정당한 이익을 부당하게 해치는 경우에는 허용되지 않는다는 것이다.²⁰⁾

이와 관련하여, 생성형 AI의 저작권 침해에 대해 공정한 이용을 인정하고자 하는 입장은 다음과 같은 근거를 제시한다. 첫째, 생성형 AI의 학습을 위한 복제, 전송도 정보 검색을 넘어 새로운 텍스트, 이미지 생성이라는 패러다임의 변화에 맞춰 이용자에게 새로운 통찰과 가치를 창출하는 행위이며, 학습 자체는 별도의 표현행위가 아니어서 생성형 AI의 데이터 학습은 변용적 이용²¹⁾으로 보아 공정한 이용에 해당한다는 것이다. 둘째, 생성형 AI의 개발은 역사의 필연적인 방향인데 데이터 학습을 위해 모든 저작자들에게 개별적으로 이용허락을 받도록 하는 것은 기술 발전에 커다란 저해를 초래한다고 본다. 셋째, 생성형 AI의 학습 데이터는 매우 방대하여 특정 저작물이 차지하는 비중은 매우 적기 때문에 저작물의 경제적 가치를 크게 훼손하지도 않는다고 주장한다.

반면에 학습 단계에서의 저작물 복제, 전송행위 등은 공정한 이용에 해당하지 않는다고 보는 입장은 다음과 같은 논거를 든다. 첫째, 생성형 AI는 특정 저작자의 문체, 그림체 등을 중점적으로 학습 가능하기도 하여, 해당 영역에서는 기존 저작물이 차지하는 비중과 그 중요성이 크다고 본다. 둘째, 기존 저작물을 학습한 생성형 AI는 유사한 저작물들을 생성할 수 있게 되어, AI 생성물이 기존 저작물의 수요를 대체할 가능성이 매우 크다는 점을 들어 공정한 이용에 해당하지 않는다고 주장한다.²²⁾

19) 최승재 · 김시열, 앞의 책, 309면.

20) 최승재 · 김시열, 앞의 책, 309면.

21) 변용적 이용이란 저작물을 이용하는 자가 원저작물에 독창적인 기여를 함으로써 새로운 저작물을 창조하는 이용을 의미한다. 저작권법의 궁극적 목적은 문화와 관련 산업을 향상 발전시키는 것이므로, 기존의 저작물을 도용하는 것이 아니라 변용적으로 이용하여 기존과는 다른 가치를 지니는 저작물을 창조한다면 이는 공공의 이익에 부합한다고 할 것이므로, 변용적 이용이라고 볼 수 있다면 공정이용으로 인정될 가능성도 높아진다고 본다. ; 최승재 · 김시열, 앞의 책, 313면 참조.

한편 공정한 이용에 관한 「저작권법」 제35조의 5는 미국 저작권법 제107조²³⁾와 미국 법원의 판례를 참고하여 만들어진 것인데, 미국은 별도의 TDM 면책 규정 없이, 공정이용 일반조항으로 사건을 해결하고 있다.²⁴⁾

2. TDM (Text & Data Mining) 면책 규정

영국이나 EU, 일본 등은 미국과 달리 별도의 공정한 이용 규정이 없다. 그에 따라 TDM 면책 규정을 통하여 일정한 조건 아래 생성형 AI의 정보 수집을 허락하고 있다. 반면에 우리나라는 공정한 이용 조항을 갖추고 있기는 하나, ① 저작물의 일반적인 이용 방법이나 ② 저작자의 정당한 이익을 해치는 것 등, 내용이 일반적이고 추상적이어서 그 해석이 다소 모호하다. 결국 사안에 따라 법원의 구체적인 판단에 의존할 수밖에 없으며, 사건마다 결과가 다르게 도출될 수 있어 법적 불안정성이 지적되었다. 이 때문에 AI 산업의 발전을 이유로 TDM(Text & Data Mining)²⁵⁾에 대해 면책 규정을 도입하여 법적 안정성을 확보하고자 하는 움직임이 있다.

아래에서는 TDM 면책 규정을 도입한 나라들의 면책 규정 내용을 간단히 살펴보고 우리나라에서 제기된 입법안을 비교하여 검토해 보고자 한다.

22) 구창훈, “생성형 AI와 저작권 이슈”, 방송문화 제427호, 한국방송협회, 2023, 33면 참조.

23) 17 U.S. Code §107 - Limitations on exclusive rights: Fair use

Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include—

(1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;

(2) the nature of the copyrighted work;

(3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and

(4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.

24) 대표적으로 Authors Guild v. Google, Inc. 사건에서 법원은 대학 도서관 내 책들을 디지털화하여 사이버 도서관 서비스를 제공한 Google에 대해, 저작물을 데이터베이스화하여 검색 기능 등을 추가한 새로운 서비스를 제공하는 경우 변용적 이용이라고 보아 공정이용에 해당한다고 보았다. ; Authors Guild v. Google, Inc., 804 F.3d 202 (2nd Cir. 2015)

25) 방대한 텍스트와 데이터를 분석하고 이를 통해 일정한 패턴을 분석하여 유용한 정보를 추출하는 기술을 말한다. ; 구창훈, 앞의 글, 34면.

(1) 영국

영국은 2014년 개정한 저작권법(CDPA) 제29A조²⁶⁾에서 텍스트와 데이터 분석(TDM)에 관한 면책 규정을 신설하였다. 해당 규정에 의하면, 저작물에 적법하게 접근할 수 있는 개인이 비상업적인 연구 목적으로만 저작물에 기록되어 있는 것을 컴퓨터로 분석하기 위해 복제물을 생성할 수 있다. 즉, ‘개인’이 ‘비상업적인 연구’ 목적으로 저작물의 복제를 할 수 있으나, 저작물에 접근할 때에도 적법하게 접근²⁷⁾할 것을 요구하며, 불가능한 경우를 제외하고 그 출처를 표시하도록 하고 있다.

(2) EU

유럽연합은 ‘유럽연합의 디지털 단일시장의 저작권에 관한 지침(EU Directive on Copyright in the Digital Single Market)’을 통하여 제3조(과학연구를 목적으로 하는 TDM)²⁸⁾

26) 「Copyright, Designs and Patents Act 1988」 29A

Copies for text and data analysis for non-commercial research

(1)The making of a copy of a work by a person who has lawful access to the work does not infringe copyright in the work provided that—

(a)the copy is made in order that a person who has lawful access to the work may carry out a computational analysis of anything recorded in the work for the sole purpose of research for a non-commercial purpose, and

(b)the copy is accompanied by a sufficient acknowledgement (unless this would be impossible for reasons of practicality or otherwise).

27) 여기서 적법한 접근이란, 라이선스 상 명시적으로 허가되어 있는 것인지, 또 저작권 침해가 발생하지 않았는지가 그 요건이 된다. ; 조연하, 앞의 책, 233면.

28) 「EU Directive on Copyright in the Digital Single Market」 Article 3

Text and data mining for the purposes of scientific research

1. Member States shall provide for an exception to the rights provided for in Article 5(a) and Article 7(1) of Directive 96/9/EC, Article 2 of Directive 2001/29/EC, and Article 15(1) of this Directive for reproductions and extractions made by research organisations and cultural heritage institutions in order to carry out, for the purposes of scientific research, text and data mining of works or other subject matter to which they have lawful access.

2. Copies of works or other subject matter made in compliance with paragraph 1 shall be stored with an appropriate level of security and may be retained for the purposes of scientific research, including for the verification of research results.

3. Rightsholders shall be allowed to apply measures to ensure the security and integrity of the networks and databases where the works or other subject matter are hosted. Such measures shall not go beyond what is necessary to achieve that objective.

와 제4조(TDM에 대한 예외 또는 제한)²⁹⁾에서 TDM 면책 규정을 마련해 두고 있다. 이에 따르면 연구기관과 문화유산기관이 과학적 연구를 수행하기 위한 데이터 복제와 추출이 허용된다는 것이다. 이 또한 합법적으로 접근이 가능한 저작물을 대상으로 하며, ‘기관(연구기관/문화유산기관)’이 ‘과학적 연구’ 목적으로 필요한 범위 내 데이터 복제와 추출이 가능하다.

이와 관련하여 독일 함부르크 지방법원은 2024년 9월 27일 Kneschke vs. LAION 사건에서 데이터셋(Dataset)의 제작 과정³⁰⁾에서 발생하는 저작권 침해와 이러한 침해가 TDM 제한 규정으로 정당화될 수 있는지에 대하여 최초로 판결하였다.³¹⁾ 여기에서 법원은 인공지능 시스템을 학습하기 위한 토대가 될 수 있는 데이터셋의 구축은 과학적 연구로 볼 수 있다고 하여 복제행위가 정당화된다고 보았다.³²⁾ 다만 해당 판결 대상은 학습용 데이터셋을 구축하는 단계로 제한하였다.³³⁾

4. Member States shall encourage rightholders, research organisations and cultural heritage institutions to define commonly agreed best practices concerning the application of the obligation and of the measures referred to in paragraphs 2 and 3 respectively.

29) 「EU Directive on Copyright in the Digital Single Market」 Article 4

Exception or limitation for text and data mining

1. Member States shall provide for an exception or limitation to the rights provided for in Article 5(a) and Article 7(1) of Directive 96/9/EC, Article 2 of Directive 2001/29/EC, Article 4(1)(a) and (b) of Directive 2009/24/EC and Article 15(1) of this Directive for reproductions and extractions of lawfully accessible works and other subject matter for the purposes of text and data mining.

2. Reproductions and extractions made pursuant to paragraph 1 may be retained for as long as is necessary for the purposes of text and data mining.

3. The exception or limitation provided for in paragraph 1 shall apply on condition that the use of works and other subject matter referred to in that paragraph has not been expressly reserved by their rightholders in an appropriate manner, such as machine-readable means in the case of content made publicly available online.

4. This Article shall not affect the application of Article 3 of this Directive.

30) AI 모델의 학습에는 대량의 데이터가 필요하므로, 프로그램을 이용하여 인터넷을 체계적으로 검색하고, 웹사이트에 있는 특히 텍스트, 이미지, 동영상, 프로그램 코드 또는 기타 디지털 콘텐츠에서 정보를 추출하는 방식으로 대량의 데이터가 자동으로 수집되어 분석되고 정리된 후 ‘데이터셋’(Dataset)이 만들어 진다. ; 박희영, “생성형 인공지능 모델 학습과 TDM 제한 - 함부르크 지방법원 판결(Kneschke vs. LAION) -”, COPYRIGHT ISSUE REPORT, 한국저작권위원회, 2024-28, 1면.

31) LG Hamburg, 27.09.2024 - 310 O 227/23

32) 박희영, 앞의 글, 5-6면 참조.

33) 박희영, 앞의 글, 7면 ; 함부르크 지방법원은 TDM 제한 조항이 적용될 수 있는 단계를 ① 학습용 데이터셋 구축, ② 인공지능 학습, ③ 학습한 인공지능의 산출의 세 단계로 구분하여 판단하고 있다.

(3) 일본

일본은 개정한 저작권법 제30조의 4³⁴⁾의 규정에 따라 TDM 면책 규정을 두고 있다. 이에 따르면 저작물에 표현된 사상 또는 감정을 향유하는 것을 목적으로 하지 않는 경우, 필요하다고 인정되는 한도에서 어떠한 방법에도 상관없이 이를 이용할 수 있다. 즉, 데이터에 표현된 사상이나 감정을 향유하는 목적이 아닌 경우 저작권 제한의 정당성을 규정한 것이다.³⁵⁾ 비록 저작권자의 이익을 부당하게 해치는 경우에는 안된다는 단서를 두고 있지만, 그 저작물이 본래의 목적으로 사용되는 경우를 제외하고는 ‘주체’나 ‘방법’에 아무런 제한이 없어 매우 적극적인 입법으로 평가되고 있다.

(4) 우리나라

우리나라는 아직 생성형 AI의 데이터 수집 및 분석에 관한 공정이용의 판례가 없어, AI 기술을 개발하는 기업 입장에서는 혹시나 발생할지 모를 형사책임을 감내하면서 데이터를 수집하고 분석하기에는 법적으로 불안한 상황이다. 이는 AI 산업의 경쟁력을 떨어뜨리며, 기술 발전에 커다란 장애물이 되므로, TDM 면책 규정을 도입하여 예측 가능성을 제공하고 산업 발전을 도모하자는 요구가 있었다.³⁶⁾ 이를 통해 데이터에 기반한 인공지능산업의 진흥을 꾀함과 동시에 면책이 없는 경우 합법적으로 사용료를 지불할 수 있는 능력이 있는 거대 자본만이 생성형 AI 산업에 진출할 수 있게 되는 문제점도

34) 일본 「저작권법」 제30조의4 (저작물에 표현된 사상 또는 감정의 향유를 목적으로 하지 않는 이용) 저작물은 다음의 경우 기타 해당 저작물에 표현된 사상이나 감정을 스스로 향유하는, 또는 타인이 향유하는 것을 목적으로 하지 않을 경우, 필요하다고 인정되는 한도에서 어떤 방법에 따라 것인지를 막론하고 이용할 수 있다. 다만 해당 저작물의 종류 및 용도와 해당 이용 양태에 비추어 저작권자의 이익을 부당하게 해치게 되는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 저작물의 녹음, 녹화, 기타의 이용에 관한 기술의 개발 또는 실용화를 위한 시험용으로 제공하는 경우.
2. 정보 해석(다수의 저작물, 기타 대량의 정보에서 해당 정보를 구성하는 언어, 소리, 영상, 기타 요소에 관한 정보를 추출하여 비교, 분류, 기타 해석을 실시하는 것을 말한다. 제47의 5 제1항 제2호에서도 동일) 용으로 제공하는 경우.
3. 전 항의 경우 외 저작물의 표현에 대한 사람의 지각에 의한 인식을 동반하지 않고 해당 저작물을 컴퓨터에 의한 정보 처리 과정에서 이용하거나 기타의 이용(프로그램의 저작물에 있어서는 해당 저작물의 전자계산기의 실행을 제외)에 제공하는 경우.

35) 조연하, 앞의 책, 237면.

36) 손영화, “생성형 AI에 의한 창작물과 저작권”, 법과 정책연구 제23집 제3호, 한국법정책학회, 2023, 380면 참조.

해소할 수 있다고 보는 것이다.³⁷⁾

이러한 요구 상황을 참고하여 다수의 저작권법 개정안³⁸⁾이 국회에 상정되었으나 국회 만기로 모두 폐기되었다.

제안 이유를 살펴보면, 해당 법안 모두 인공지능·빅데이터 등 신기술의 발전으로 대량의 정보를 분석·활용하는 경우가 많아지면서 저작물을 허락없이 이용하는 사례가 늘고 있는데, 이 경우 현행 ‘공정이용’ 조항의 적용여부가 불분명하므로 데이터마이닝을 이용한 자동화된 정보 분석을 위한 저작물 이용에 대하여 법률에 명시적 기준을 마련하자는 것이다. 이를 통해 데이터 관련 산업의 활성화와 관련 사업자의 활동 영역을 보장하려는 것이었다.

다만 다른 의안과 달리 이인영 의원안은 ‘비상업적’ 목적인 정보 분석으로 제한하고 있다. 또한 저작재산권 제한 규정을 적용할 수 있는 요건으로 ① 대학·연구기관 또는 그 밖에 대통령으로 정하는 기관이나 단체에서 수행할 것, ② 교육·조사·연구 등 비상업적 목적으로 이용할 것, ③ 정보분석의 대상이 되는 해당 저작물에 대하여 적법하게 접근할 것을 규정하고 있다.

또, 황보승희 의원안은 저작재산권을 제한하는 요건으로 ① 해당 저작물에 대하여 적법하게 접근할 것, ② 해당 저작물에 표현된 사상이나 감정을 향유하는 것을 목적으로 하지 아니할 것을 요구하고 있으나, 저작물을 이용하는 방법에 있어서 복제·전송 뿐만 아니라 2차적저작물을 작성하는 것까지 포함하고 있는 것이 큰 특징이다.

마지막으로 이용호 의원안에서는 황보승희 의원안과 동일하게 ① 저작물에 표현된 사상이나 감정을 향유하지 아니할 것, ② 정보분석의 대상이 되는 해당 저작물에 적법하게 접근할 것을 요구하고 있고, 이용 방법은 복제와 전송행위로 제한하고 있다. 다만 정보 분석의 결과물, 즉 생성된 결과물에 대해서도 규정을 두어, ① 교육·조사·연구 등 비상업적 목적 ② 저작물의 창작 목적으로 적법하게 접근하는 경우에는 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」, 「데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법」, 「산업 디지털 전환 촉진법」 및 그 밖의 데이터 보호에 관한 다른 법률에도 불구하고 해당 결과물을 이용할 수 있다고 하여 타 법상의 데이터에 관한 권리를 배제하고 있다.

37) 이지연·김원호, 앞의 글, 96-97면.

38) 이용호 의원 대표 발의, 「저작권법 일부개정법률안」, 의안번호 2117990호, 2022.10.31. ; 황보승희 의원 대표 발의, 「저작권법 일부개정법률안」, 의안번호 2122537호, 2023.06.08. ; 이인영 의원 대표 발의, 「저작권법 일부개정법률안」, 의안번호 2124685호, 2023.09.25.

3. 소결

일본을 비롯한 EU, 영국, 미국 등은 AI 기술과 관련하여 데이터 학습이나 처리 과정에서 저작권 문제를 해결하고자 저작권법에 특별규정을 두어 면책하거나 공정이용 원칙에 따라 저작재산권에 제한을 두고, 저작권 침해에서 벗어날 수 있도록 하고 있다.

우리나라는 「저작권법」 제35조의 5의 공정한 이용 규정에도 불구하고 기계적인 데이터 수집과 분석의 적법성 여부에 관한 명확한 선례가 없어 해당 조항이 적용되는지, 구체적으로 어느 범위까지 적용할 수 있는지에 대한 해석이 명확하지 않다. 생각건대 생성형 AI의 등장으로 다양한 분야에서 AI의 활용이 늘어나고 있는바, 인간의 원저작물이 AI 생성물로 대체될 수 있는 것은 자명하다. 그에 따라 생성형 AI가 아무런 제한이나 허락 없이 저작자의 저작물을 학습하여 그것들과 경쟁한다는 것은, 원저작물의 시장가치에 영향을 주게 되며,³⁹⁾ 저작자의 정당한 이익을 부당하게 해치는 경우라 여겨진다. 따라서 생성형 AI의 저작권 침해에 대해 공정한 이용 규정은 적용되지 않는 것이 타당하다.

무엇보다 저작재산권의 제한으로 저작물을 이용하는 자는 그 출처를 명시해야한다. 즉, 「저작권법」 제37조⁴⁰⁾에 따라, 공정이용으로 인정받기 위해서는 출처명시의무 또한 가지게 되므로, 현재 학습한 데이터의 출처를 명시하지 않은 생성형 AI의 저작권 침해 행위와 관련하여 공정이용으로 인정받기는 어렵다. 또한, 저작재산권과 별개로 저작권격권에 관련해서는 공정한 이용이 미치지 아니하므로,⁴¹⁾ 앞서 언급한 동일성유지권, 성명표시권은 여전히 침해가 된 것으로 볼 수 있다.

또, TDM 면책 규정과 관련하여 살펴보면, 우리나라의 입법안으로 올라온 규정은 이인영 의원 외 ‘저작물에 표현된 사상이나 감정을 향유하지 아니할 것’을 요구하고 있어, 일본 저작권법의 면책 규정을 참고로 한 것으로 보인다. 다만 여기에 복제나 전송행위(혹은 2차적 저작물작성행위)와 같은 이용 방법에 제한을 두어 면책 범위에 제한을 두

39) 생성형 AI가 원저작물과 유사한 풍의 2차 저작물들을 만들어내고 이러한 2차 저작물들이 대량 유통된다면 해당 저작 산업의 전반을 잠식시킬 수 있는 위험이 존재하게 된다. ; 방정미, “생성형 인공지능의 저작권 침해 예외 규정으로서 공정이용 법리의 유효성에 관한 시론적 고찰”, 유럽헌법연구 제44호, 2024, 298-299면.

40) 제37조(출처의 명시) ① 이 관에 따라 저작물을 이용하는 자는 그 출처를 명시하여야 한다. 다만, 제26조, 제29조부터 제32조까지, 제34조 및 제35조의2부터 제35조의4까지의 경우에는 그러하지 아니하다.

41) 제38조(저작인격권과의 관계) 이 관 각 조의 규정은 저작인격권에 영향을 미치는 것으로 해석되어서는 아니 된다.

고 있다. 또 다른 제한으로 정보 분석의 대상이 되는 저작물에 적법하게 접근할 것을 요구하고 있는데, 이에 대한 의미가 명확하지 않다. 저작물에 대한 라이선스를 취득하여 접근해야 하는 것인지, 해킹, 불법 다운로드 등을 통한 접근을 배제한다는 것인지 명확히 해둘 필요가 있다. 또한 이인영 의원안은 '비상업적 목적으로 이용하는 경우'로 제한하고 있는데, 비상업적으로 데이터 학습을 하였다하더라도 그 결과물은 상업적으로 이용이 가능할 수 있으므로, 이에 대한 적용여부도 문제가 될 수 있다.

무엇보다 아직 저작권자 측과 AI 산업 측의 논의와 합의가 이루어진 적이 없는 상황에서 선불리 TDM 면책 규정을 도입하는 것은 더 큰 갈등을 키울 우려가 있다. AI 산업 발전을 이유로 아무런 허락이나 보상 없이 다른 사람의 저작물을 일괄적으로 사용할 수 있게 하는 것은 저작권자의 저작권을 과도하게 침해하는 것이다. 상호 이해관계가 정돈되고 일방적인 희생을 강요하지 않는 구체적인 해결 방안이 나왔을 때 양측의 균형을 맞추는 개정을 하는 것이 효율적이라 여겨진다. 생성형 AI와 관련한 저작권 침해 문제를 해결하기 위해서는 사전에 저작권자들의 허락을 받는 것이 가장 이상적이지만, 불가능하다면 최소한 수집을 거부할 수 있는 권리가 부여되어야 할 것이다.

Ⅳ. 저작권 침해에 따른 형사책임과 개선방안

1. 생성형 AI의 활용에 따른 저작권 침해와 형사책임

우리 형법은 범죄 행위의 주체가 될 수 있는 자를 범죄능력이 있는 자, 즉 자연인에 한정하고 있다. 인공지능은 사람에 의하여 프로그래밍되고 사람에 의하여 활용되는 과학기술인 일종의 도구로 볼 수 있다. 책임비난이 가해지는 형사책임이 귀속되기 위해서는 행위자에게 행위능력과 책임능력이 있어야 하므로, 이러한 능력이 없는 생성형 AI는 현행법상 형사책임을 질 수 있는 대상이 아니다.⁴²⁾ 따라서 생성형 AI가 타인의 저작물을 무단으로 이용하여 저작권을 침해한 경우, 그에 대한 형사책임은 누구에게 귀속될 것인지 문제가 될 수 있다. 이 또한 개발 및 학습 단계와 생성물 생성 및 활용 단계로

42) 윤지영, “생성형 AI 시대의 사이버범죄와 형사법적 대응”, 법학연구 제24권 제1호, 연세대학교 법학연구원, 2024, 382-383면 참조.

나누어서 살펴보아야 할 것이다.

우선 생성형 AI를 개발 및 학습하는 단계에서의 저작권 침해에 대한 책임은 인공지능 개발자, 즉 사업자에게 귀속되어야 한다.⁴³⁾ 개발 및 학습 시에는 개발하는 사업자가 알고리즘을 통해 주도적으로 학습 데이터를 수집하고 활용하기 때문이다. 개발자는 저작권자의 동의를 얻은 저작물이나 데이터만을 이용해야 한다. 타인의 저작물을 출처표시 없이 자기 것처럼 부당하게 사용하는 것은 전형적인 저작권 침해행위이다.

반면에 학습이 완성된 생성형 AI가 만들어낸 생성물과 관련하여 저작권 침해가 발생한 경우에는 개발자의 관리 범위를 벗어나고 인공지능 스스로가 생성물을 만들어내므로, 그 책임에 관련하여 견해가 나뉜다. 명령어를 입력하여 그 생성물을 만들어낸 이용자나 생성형 AI 서비스를 만들어 배포한 자에게 책임 문제가 발생할 수 있는데, 원저작물의 저작권을 침해하는 생성물이라면 이 생성물을 제작하고 공중이 이용할 수 있도록 한 이용자(즉, AI에게 무엇을 만들 것인지 지시한 자)가 침해죄에 대한 책임을 져야 할 것이다.⁴⁴⁾ 생성형 AI 프로그램을 사용한 이용자가 AI라고 하는 도구를 이용하여 저작권 침해물을 만들어낸 것이고, 저작권 침해행위에 직접적으로 관여를 한 자이므로 그에 맞는 책임을 지는 것이 타당하다.

이 경우 AI를 제작하고 배포한 업체도 책임여부가 문제될 수 있다. 특히, 생성형 AI 프로그램상의 결함으로 인하여 문제가 발생한 경우라면, 이에 대해서는 이용자가 모든 책임을 지는 것은 맞지 않다.⁴⁵⁾ 결함있는 프로그램을 만들어 배포한 업체 또한 이에 대한 책임을 져야 한다. 생성형 AI의 개발자와 운영자는 학습 단계 뿐만 아니라 이들이 활용되는 단계에서도, 저작권 침해에 해당하는 정보를 생성해 내지 않도록 기술적 조치를 취해야 한다.

2. 기존 저작권법에 따른 처벌 가능성

생성형 AI에 의하여 저작권이 침해된 경우, 「저작권법」 제136조⁴⁶⁾에 따라 AI 사업자

43) 김효정·이호용, 앞의 글, 42면 참조 ; 이지연·김원호, 앞의 글, 110면.

44) 김경숙, “인공지능(AI) 생성물과 저작권 문제”, IT와 법연구 제27집, 경북대학교 IT와 법연구소, 2023, 60-61면 ; 김효정·이호용, 앞의 글, 43면 ; 손영화, 앞의 글, 373면 ; 조연하, 앞의 책, 225면.

45) 김재윤, “생성형 인공지능(AI)을 이용한 명예훼손 범죄의 책임귀속 주체와 그 내용에 관한 고찰”, 비교형사법연구 제26권 제3호, 한국비교형사법학회, 2024, 224면 참조.

46) 제136조(벌칙)

혹은 이용자를 처벌할 수 있다. 앞에서 살펴본 바와 같이, 저작권 제한 규정인 공정한 이용에 적용될 가능성은 적으며, 설사 적용된다고 하더라도 학습한 데이터를 밝히지 않은 이상 제37조 제1항의 출처명시의무 위반으로 처벌될 수 있다.⁴⁷⁾

또한 공정한 이용으로 저작권은 제한이 되더라도 저작인격권은 이에 해당되지 않기 때문에 저작인격권 침해에 따른 처벌은 여전히 인정된다. 다만, 저작인격권을 침해한 것으로 끝나는 것이 아니라, 그로 인해 저작자의 명예를 훼손한 경우에 한하여 처벌하고 있다. 즉, 생성형 AI가 이용한 저작물에 대한 저작자의 성명을 표시하지 않거나 그 저작물이 학습·이용하는 과정에서 변경되어 저작자의 명예가 훼손되는 경우에만 침해로 보기 때문에 다소 제한적으로 활용될 수 있다.

그리고 만약 생성형 AI가 저작권을 침해하여 만들어진 복제물이나 그 복제물의 제작에 주로 사용된 도구나 재료에 해당한다면 AI 프로그램의 몰수도 가능할 것이다.⁴⁸⁾ 지식재산권 자체가 무형자산으로 형체가 없는 것이므로 저작권 침해에 대한 몰수 대상을 물건에만 한정하는 것은 적합하지 않기 때문이다.

최근에는 생성형 AI의 학습 대상이 되는 것을 피하기 위해 저작물에 AI 학습금지 표시를 하거나 저작물의 무단 학습을 방해하는 기술적 조치⁴⁹⁾를 취하는 경우도 있다. 이

① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과(併科)할 수 있다.

1. 저작권, 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 재산적 권리(제93조에 따른 권리는 제외한다)를 복제, 공연, 공중송신, 전시, 배포, 대여, 2차적저작물 작성의 방법으로 침해한 자

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과할 수 있다.

1. 저작인격권 또는 실연자의 인격권을 침해하여 저작자 또는 실연자의 명예를 훼손한 자

47) 제138조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 500만원 이하의 벌금에 처한다.

2. 제37조(제87조 및 제94조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)를 위반하여 출처를 명시하지 아니한 자

48) 제139조(몰수) 저작권, 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리를 침해하여 만들어진 복제물과 그 복제물의 제작에 주로 사용된 도구나 재료 중 그 침해자·인쇄자·배포자 또는 공연자의 소유에 속하는 것은 몰수한다.

49) 대표적으로 나이트셰이드(Night Shade)와 글레이즈(Glaze)가 있는데, 나이트셰이드는 인공지능이 창작자의 허가 없이 접근해 정보를 학습할 경우 인공지능 모델의 신뢰도와 정확성이 치명적 손상을 입게 되는 새로운 저작권 보호 도구로서, 창작자가 작품을 온라인에게 공개하면서 해당 기술을 이용해 독성코드를 삽입하면, 해당 데이터를 수집한 인공지능 모델 안에서 독이 나며 데이터로 퍼져나가 전체 모델이 오염되는 방식이다. 한번 오염된 데이터는 삭제하기 매우 어렵기 때문에 인공지능 모델은 치명적 손상을 입게 된다. ; 이상미, “AI 학습데이터 무단 사용에 대한 저

러한 기술적 조치들은 「저작권법」 제2조 제28호의 ‘기술적 보호조치’에 해당할 수 있고, 업이나 영리를 목적으로 이를 무력화할 경우, 제104조의 2 제1항과 제136조 제2항에 따라 처벌될 것이다.⁵⁰⁾

3. 형사정책적 개선방안

(1) 저작권 침해죄에 대한 제언

우리나라는 실무상 저작권에 대한 침해가 인정되어 저작권 침해죄로 처벌하기 위해서는 객관적 요건으로서 실질적 유사성이 있어야하고, 주관적 요건으로 의거성(접근성)이 요구된다.⁵¹⁾ 결국 생성형 AI의 생성물이 기존의 저작물과 실질적으로 유사할 뿐만 아니라, AI 생성물이 기존의 저작물에 의거해서 만들어졌다는 것을 침해 주장자가 입증해야 한다.

AI 업계에서는 일반적으로 학습데이터의 내용을 공개하지 않고 있다. 따라서 광범위한 데이터에서 원저작물을 정확하게 특정하는 것은 사실상 가능하지 않으므로 기존의 저작물에 대한 의거성과 유사성을 입증하기가 어렵다.⁵²⁾ 단순한 가능성이나 의심만으로는 유사성이나 의거성이 인정되지 않기 때문이다.

미국의 Getty Images (US) Inc. v. Stability AI Inc. 사건의 경우, 생성된 이미지가 Getty Images의 저작물과 유사하고, Getty 특유의 워터마크가 변형되어 포함되어 있었기 때문

작권 보호 방안 - 블록체인 기술을 활용한 확대된 집중관리제도의 도입을 중심으로 -, 계간 저작권 제37권 제2호, 한국저작권위원회, 97면. 또 글레이즈는 AI 모델이 특정 아티스트의 고유한 스타일을 복제하지 못하도록 보호하기 위하여 개발된 것으로, 이미지 픽셀을 미묘하게 변경함으로써 AI의 혼란을 야기한다. ; 이상미, 앞의 글, 97면 참조. 다만, 이러한 기술적 조치를 취할 경우 타인의 AI 프로그램 전체를 무용지물로 만들 수 있으므로, 학습금지 표시나 경고를 함께 해두는 것이 좋을 것이다.

50) 제104조의2(기술적 보호조치의 무력화 금지) ① 누구든지 정당한 권한 없이 고의 또는 과실로 제2조제28호가목의 기술적 보호조치를 제거·변경하거나 우회하는 등의 방법으로 무력화하여서는 아니 된다.

제136조(벌칙) ②다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과할 수 있다.

3의3. 업으로 또는 영리를 목적으로 제104조의2제1항 또는 제2항을 위반한 자

51) 정상조 (편), 앞의 책, 1310-1311면.

52) 박유선, “생성형 인공지능(AI)의 스타일 모방의 저작권 침해에 관한 연구, 산업재산권 제76호, 2023, 438-439면.

에, 의거성이 입증되기도 하였다.⁵³⁾ 그러나 이러한 경우를 제외하고는 일반적으로는 인공지능이 내부적으로 데이터를 어떻게 처리하는지 알 수 없기때문에, '생성형 AI의 학습 데이터 목록이 공개되지 않는 이상' 의거성을 입증하기가 어렵다.

그렇지만 반대로 해당 저작물이 학습 단계에 포함되어 있는 데이터인지 여부를 확인할 수 있다면 저작권자의 입장에서는 의거성을 쉽게 입증할 수 있게 된다. 뿐만 아니라 AI 업계에서도 만약 해당 데이터를 활용하지 않았다면, 부당하게 저작권을 침해했다는 의심으로부터 벗어날 수 있을 것이다.

한편, 저작권법상 저작권 침해죄로 처벌하는데 고의를 명시적으로 언급하고 있지는 않지만, 벌칙의 적용에는 형법총칙 규정이 당연히 적용되어야 한다. 따라서 주관적 요건으로 의거성과는 별개로 행위자의 고의 여부를 반드시 판단해야한다.

우선 개발 및 학습 단계에서 AI 개발자가 허락받지 않은 타인의 데이터라는 것을 인식하면서도 이를 학습시킨 생성형 AI를 제작하여 배포한 경우, 개발자는 고의가 인정되어 저작권 침해의 책임을 진다. 그리고 설사 저작권 침해에 대한 인식이 없더라도, 자신들이 개발하고 배포한 생성형 AI가 만들어낸 생성물이 지속적으로 저작권을 침해하고, 그것이 AI 이용자의 행위에 의한 침해가 아님에도 불구하고 AI 개발자 측에서 아무런 조치를 취하지 않고 방치하였다면, 미필적 고의를 인정하여⁵⁴⁾ 저작권 침해가 된다고 보는 것이 타당하다.

다음으로 활용 단계에서 생성형 AI를 도구로 이용하는 자는 타인의 저작권을 침해하는 것을 인식하면서도 그러한 생성물을 만들 것을 지시하고 그 결과 저작권을 침해하는 결과물을 만들어냈다면 고의가 인정되어 저작권 침해로 처벌됨이 마땅하다. 이 경우 저작권 침해를 발생하게 한 도구를 만들어낸 개발자와 제작자 측에 관해서도 책임을 부과해야한다는 견해도 있지만, 자신의 프로그램을 사용하는 이용자가 어떤 목적으로 AI를 사용하는지 사전에 알지 못하는 상황에서 생성형 AI 개발자의 저작권 침해에 대한 고의를 인정할 수는 없다.

다만 개발자도 프로그램을 제공한 이상 지속적으로 프로그램의 이용 현황을 살펴면서 자신들이 배포한 AI가 악용되거나 다른 사람의 법익을 침해하고 있지 않은지 모니터링을 하며 생성형 AI를 지속적으로 관리·감독해야 한다. 그에 따라 이러한 관리·감독

53) Getty Images (US) Inc. v. Stability AI Inc. 1:23-cv-00135-UNA (2023.02.03.)

54) 김재윤, 앞의 논문, 225면 참조.

을 제대로 이행하지 않아 발생하게 된 저작권 침해의 경우, ‘과실에 의한 저작권 침해’도 인정할 필요가 있다. 물론 현행 저작권법에는 과실범의 규정이 없어 과실로 인한 저작권 침해의 처벌이 불가능하다.

그러나 생성형 AI의 개발자와 운영자들에게 저작권 침해에 해당하는 정보를 생성해 내지 않도록 기술적 조치를 취하고, 이용자들이 악용하지 않도록 꾸준히 모니터링을 하도록 법적 의무를 부과할 필요가 있다. 그리고 이를 제대로 이행하지 않을 경우, 과실로 인한 책임을 지도록 저작권 침해죄에 대한 과실범 처벌 규정이 보완되어야 한다. 물론 관리·감독을 충실히 이행한 경우에는 처벌이 배제되어야 할 것이다.

(2) 제한적 면책 규정의 도입

생성형 AI가 기존의 저작물을 침해하는 부분이 있긴 하지만 AI의 활용이 이제 우리 일상생활의 일부분이 된 만큼, AI가 적법하게 저작물을 학습하고 그 생성물을 이용할 수 있도록 할 필요가 있다. 이는 첨단 과학기술과 공존해 가는 우리 시대에 꼭 필요한 과정이다.

인공지능의 특성상 현재 우리나라에서 공정한 이용 법리를 적용하기는 어렵다. 따라서 구체적인 조건 아래에서 적용이 될 수 있는 실효적인 TDM 면책 규정이 필요하다.⁵⁵⁾ 지나치게 포괄적이고 일반적인 면책은 저작권자들의 반발만 불러일으키기 때문이다.

우선 개발 및 학습 단계에서 AI 개발자와 운영자들이 준수해야 할 의무를 확립해야 한다. 생성형 AI가 저작물로 인정되는 정보나 데이터를 학습할 때 저작권자의 사전 동의를 받는 것이 가장 원칙적이고 이상적이다. 하지만, 대량의 데이터를 짧은 시간 안에 수집·학습하고 그 결과물을 내놓은 생성형 AI의 특성상 모든 저작권자의 사전 동의를 받는 것은 현실적으로 불가능하다.

따라서 생성형 AI가 학습에 이용한 원본 저작물들을 투명하게 제공하는 기술을 함께 사용하여, 이들이 학습을 위해 활용한 데이터 출처를 의무적으로 공개하도록 해야 한다. 그에 따라 자신의 저작물이 이용된 저작권자가 사후에라도 이를 확인하여 저작물 이용 허락 여부를 결정할 수 있도록 해야 할 것이다.

또한 저작권자들에게 자신의 저작물에 대해 생성형 AI의 접근을 거부할 수 있는 권

55) 이수경, “인공지능과 저작권 침해의 문제”, 재산법연구 제41권 제2호, 한국재산법학회, 2024, 58면.

리를 부여해야한다. AI 학습 금지 표시나 거부 표시가 없는 저작물만 수집하고 학습함으로써, 생성형 AI에게도 이용의 정당성을 확보시켜줄 수 있을 것이다.

그리고 생성 및 활용 단계에서 AI 개발자와 운영자는 생성형 AI를 활용한 생성물에 ‘AI’등의 워터마크가 자동으로 표시되도록 하여 이를 접하는 사람들이 그에 대한 정보를 알 수 있도록 해야한다.⁵⁶⁾ 타인의 저작물을 이용하여 만들어진 AI 생성물임에도 마치 이용자의 창작물인 것처럼 보여질 경우, 이 또한 저작권 침해가 된다. 따라서 AI 생성물인 것을 나타내는 워터마크 표시를 의무화하면서 그와 동시에 이용된 저작물의 출처와 목록들을 밝히도록 해야한다.

생성형 AI를 활용하는 이용자들은 기본적으로 생성형 AI를 악용하는 행위를 금지해야하며,⁵⁷⁾ AI 업체를 통하여 자동으로 표시되는 워터마크나 출처표시를 제거하지 못하도록 해야한다. 그리고 AI 업체들은 지속적으로 자신들이 제공한 프로그램이 저작권 침해를 하지 않도록 모니터링하며, 그러한 침해를 사전에 방지할 수 있는 시스템을 구축해둬야 한다.

이러한 구체적인 개선방안을 마련한 후 TDM 면책 규정을 도입한다면, AI 업계에서는 안정적으로 저작물을 수집·복제하고 이를 학습에 이용하여 학습 완료한 AI를 개발하는 것이 가능하게 될 것이다. 저작권자의 측면에서도 원하지 않으면 생성형 AI의 학습에 이용되지 않을 수 있고, 또 학습에 이용된 목록을 쉽게 확인할 수 있으므로, 자신의 의사에 반하는 저작물의 복제나 전송이 발생하면 저작권 침해 요건인 유사성이나 의저성을 입증하기가 쉬워 저작권 보호를 받기에 용이하다.

생성형 AI의 활용이 빠르게 대중화되고 있는 이상, 형사정책적 대응도 뒤처지지 않게 구비해둘 필요가 있다. 타인의 저작물을 무분별하게 이용하는 AI 생성물에 적절한 법적 규제가 이루어져야 한다. 생성형 AI를 이용한 창작물들이 무분별하게 제작되고 유포되지 않도록, 프로그램 운영자와 이용자들에게 기본적인 의무와 규제를 부과해둘 필요가 있다.

학습데이터로 사용되는 저작물의 무단 학습을 방해하는 기술개발도 나오고 있는 상

56) 이원상, “생성형 인공지능의 범죄위험성 예측 및 형사정책적 대응방안”, 비교형사법연구 제26권 제3호, 한국비교형사법학회, 2024, 114면.

57) 김정화 · 임동민 · 차호동, “생성형 인공지능(Generative AI) 기술의 규제 방향에 대한 입법론적 고찰 - ChatGPT 등 인공지능 시스템 생성물에 대한 표시·고지의무를 중심으로 -”, 형사법의 신통향 통권 제80호, 대검찰청, 2023, 265면.

황에서, 저작자와 AI 업계가 서로 힘겨루기만 하는 것은 문화 및 산업의 발전에도 방해가 될 뿐이다. 서로의 상생을 위해 협의안을 만들어갈 시점이다.

V. 나가며

오늘날 AI 기술은 급속도로 발달하며 각종 사회 시스템 속에 빠르게 스며들고 있다. 그 중에서도 인간처럼 다양한 창작물을 생성해 낼 수 있는 생성형 AI는 다양한 분야에서 활용되며 우리에게 효율성과 편리함을 가져다 주고 있다. 하지만 이를 위해 창작자의 노력과 권리에 대한 희생을 강요할 수는 없다.

생성형 AI는 결과물을 생성하는 경우 뿐만 아니라 그 개발과 학습 단계 때부터 다른 저작권자의 저작권을 침해하며 만들어지는 프로그램이다. 우리나라 저작권법에 따른 공정한 이용의 규정으로는 생성형 AI에 대해 저작권을 제한할 수 없으며, AI 산업 발전을 이유로 해당 업계의 편리함 위주로 선불리 면책 규정을 만들어 도입하는 것은 더 큰 혼란만 초래할 것이다. 무엇보다 저작권 침해가 될 수 있는 영역을 명확히 한 후, 일정한 의무를 부과하여 제한적으로 면책을 할 수 있도록 해야한다.

생성형 AI를 이용하여 만들어진 생성물을 저작물로 볼지, 저작권법으로 보호할지 여부를 논의하기에 앞서 사람인 기존 창작자의 권리부터 보호해야 한다. 인간의 저작물이 보호되지 않고 이를 근거로 한 모방적 생성물인 AI의 작품들이 넘쳐나게 되면, 결국에는 AI 생성물들이 인간의 저작물을 대체하게 될 것이다. 그렇게 되면 인간의 창작 의욕은 떨어지고, 창작행위가 더 이상 이루어지지 않을 수도 있다. 그에 따라 생성형 AI 또한 더 이상 학습할 수 있는 데이터가 없어서 우리의 문화와 산업 수준은 더 퇴보될 수도 있는 것이다.

AI의 발전과 일상화는 거스를 수 없는 흐름이기는 하나 지나친 기술 의존과 산업 발전 중심적 사고는 여러 위험을 품고 있다. 저작권의 영역도 마찬가지다. 저작권법의 목적은 저작권자의 권리를 보호하여 저작물의 공정한 이용을 도모하여 문화 관련 산업을 향상시키고 발전시키는 것이다. 효율성과 편리함만 쫓아 AI 개발에만 집중하며 개인의 권리 희생을 강요할 것이 아니라, 함께 상생할 수 있는 법체계를 갖추나갈 필요가 있다.

참고문헌

<단행본>

- 윤태식, 저작권법 (제2판), 박영사, 2021
저작권위원회, 생성형 AI 저작권 안내서, 2023
정상조 (편), 저작권법 주해, 박영사, 2007
조연하, 인공지능 창작과 저작권, 박영사, 2023
최승재 · 김시열, 저작권법, 법문사, 2024

<논문>

- 구창훈, “생성형 AI와 저작권 이슈”, 방송문화 제427호, 한국방송협회, 2023, 30-43
김경숙, “인공지능(AI) 생성물과 저작권 문제”, IT와 法연구 제27집, 경북대학교 IT와 법 연구소, 2023, 33-72
김재윤, “생성형 인공지능(AI)을 이용한 명예훼손 범죄의 책임귀속 주체와 그 내용에 관한 고찰”, 비교형사법연구 제26권 제3호, 한국비교형사법학회, 2024, 217-250
김정화 · 임동민 · 차호동, “생성형 인공지능(Generative AI) 기술의 규제 방향에 대한 입법론적 고찰 - ChatGPT 등 인공지능 시스템 생성물에 대한 표시 · 고지의무를 중심으로 -”, 형사법의 신통향 통권 제80호, 대검찰청, 2023, 245-283
김혜정 · 송현수 · 박용주, “인공지능(AI) 윤리 규제 동향 및 표준화 현황”, 인공지능윤리 연구 제3권 제2호, 한국인공지능윤리학회, 2024, 6-33
김효정 · 이호용, “이미지 생성형 AI의 학습데이터 이용과 원저작권자의 이해관계조정 - 저작물의 공정이용과 외부효과를 중심으로 -”, 강원법학 제72권, 강원대학교 비교법학연구소, 2023, 29-56
명순영 · 최창원, “소송당하는 ‘생성형 AI’ : 잘나가는 챗GPT · · · 저작권에 발목?”, 매경 ECONOMY 통권 제2217호, 46-48
박서현 · 가지현, “생성형 AI 창작물의 저작권 성립 여부 및 침해 요건 검토 - 창작성 판단 기준과 차용미술과의 비교를 중심으로-”, 디자인 이노베이션 연구 제12호, 서경대학교 부설 디자인연구소, 2024, 23-48
박유선, “생성형 인공지능(AI)의 스타일 모방의 저작권 침해에 관한 연구”, 산업재산권

제76호, 2023, 431-454

박희영, “생성형 인공지능 모델 학습과 TDM 제한 - 함부르크 지방법원 판결(Kneschke vs. LAION) -”, COPYRIGHT ISSUE REPORT, 한국저작권위원회, 2024-28

방정미, “생성형 인공지능의 저작권 침해 예외 규정으로서 공정이용 법리의 유효성에 관한 시론적 고찰”, 유럽헌법연구 제44호, 2024, 269-303

손영화, “생성형 AI에 의한 창작물과 저작권”, 법과 정책연구 제23집 제3호, 한국법정책학회, 2023, 357-389

윤지영, “생성형 AI 시대의 사이버범죄와 형사법적 대응”, 법학연구 제24권 제1호, 연세대학교 법학연구원, 2024, 373-399

이상미, “AI 학습데이터 무단 사용에 대한 저작권 보호 방안 - 블록체인 기술을 활용한 확대된 집중관리제도의 도입을 중심으로 -”, 계간 저작권 제37권 제2호, 한국저작권위원회, 79-121

이수경, “인공지능과 저작권 침해의 문제”, 재산법연구 제41권 제2호, 한국재산법학회, 2024, 35-64

이원상, “생성형 인공지능의 범죄위험성 예측 및 형사정책적 대응방안”, 비교형사법연구 제26권 제3호, 한국비교형사법학회, 2024, 93-123

이지연·김원호, “저작물 학습자로서 생성형 AI의 저작권 침해 책임”, IP & Data 法 제4권 제1호, 인하대학교 법학연구소, 2024, 75-120

<국문요약>

생성형 AI의 등장은 우리들에게 혁신적인 변화를 가져왔다. 기존의 데이터를 학습하여 ‘새로운’ 결과물을 제공하며, 다양한 분야에서 편리하게 활용되는 도구가 되었다. 기존의 것을 학습하여 창작물을 만들어내는 것은 인간의 창작활동과 유사하나, 학습할 수 있는 자료나 데이터가 없는 이상 결과물을 만들어낼 수 없기에, 인간의 창작물을 필연적으로 이용할 수밖에 없는 구조를 띄고 있다.

그에 따라 생성형 AI를 학습시키는 과정에서, 또 생성물을 만들어내기 위해 이용하는 과정에서 기존의 저작물들을 활용할 수밖에 없으므로 복제권, 전송권, 2차적 저작물작성권 등 저작권자의 저작권을 침해하게 된다.

이와 관련하여 관련 산업의 활성화와 발전을 위해, 생성형 AI의 학습은 저작권이 제한되는 ‘공정한 이용’에 해당한다고 보거나, 애초에 저작권 침해에 해당하지 않도록 하는 ‘면책 규정’의 도입을 주장하기도 한다.

그러나, 생성형 AI의 학습과 이용은 공정한 이용에 따른 저작권 제한 요건에 해당한다고 보기 어렵다. 또, 아직 저작권자 측과 아무런 합의가 이루어지지 않은 상태에서 선 부른 면책 규정 도입은 더 큰 혼란만 가져올 것이다.

산업 발전을 이유로 저작권자의 일방적인 희생을 요구할 것이 아니라, 우선은 저작권 침해가 될 수 있는 영역을 명확히 하고, 생성형 AI가 학습한 저작물의 목록을 공개하거나 최소한 저작권자들이 수집 거부할 수 있는 권리를 갖춘 후에 면책 규정을 적용할 수 있도록 해야 할 것이다.

또한 생성형 AI를 개발하고 운영할 때, 저작권 침해가 발생하지 않도록 꾸준히 관리·감독을 하도록 법적 의무를 부과할 필요가 있다. 그리고 이러한 의무를 다하지 못할 때, 과실로 인한 책임을 지도록 저작권 침해죄에 대한 과실범 처벌 규정이 보완되어야 할 것이다.

주제어 : 생성형 AI, 저작권 침해, 형사책임, 공정한 이용, TDM 면책 규정

<Abstract>

Copyright Infringement following the Use of Generative AI and Criminal Policy Improvement Measures

*Kang, Miyoung**

The emergence of generative AI has brought about revolutionary changes for us. It has become a tool that is conveniently used in various fields by learning from existing data and providing 'new' results. Learning from existing things and creating creative works is similar to human creative activities. However, since it is impossible to create results without learning materials or data, it has a structure that inevitably has to use human creative works.

Accordingly, in the process of learning generative AI and in the process of using it to create results, existing works have no choice but to be used, thereby infringing on the copyright holder's copyright.

In relation to this, in order to activate and develop related industries, it is argued that the learning of generative AI corresponds to 'fair use' subject to copyright restrictions, or that an 'exception provision' should be introduced to prevent it from being a copyright infringement in the first place.

However, it is difficult to say that the learning and use of generative AI falls under the requirements for copyright restrictions based on fair use. In addition, hasty introduction of exception regulations while no agreement has yet been reached with the copyright holder will only lead to greater confusion.

We should not demand unilateral sacrifices from copyright holders in the name of industrial development. First of all, it is necessary to clarify the areas where copyright infringement can occur and to make the list of works learned by generative AI public, or at least allow copyright holders to have the right to refuse collection before applying exception regulations.

* Instructor, Law School, Pusan National University, Ph.D. in Law.

In addition, when developing and operating generative AI, it is necessary to impose a legal obligation to continuously manage and supervise to prevent copyright infringement. When these obligations are not fulfilled, the provisions for punishment of negligence for copyright infringement should be supplemented to ensure that liability for negligence is assumed.

Key Words : Generative AI, Copyright Infringement, Criminal Liability, Fair Use, TDM
Exceptions